

東京地方裁判所民事第2部C係 御中

意 見 書

立命館大学大学院法務研究科教授
博士（法学・一橋大学）

三木 義一

平成19年4月25日

はじめに

本件の争点についての検討を始める前に、ここ数年の税制改革はきちんとした改正の議論がないまま年末に突如与党の改正案が示され、納税者に周知されることなく改正手続がなされ、実施過程で各種のトラブルが生じていることを是非ご理解いただきたい。老年者控除の突如の廃止とその影響を受けた自治体窓口の混乱、本件改正による実務家の大混乱、それに続き18年改正による役員給与改正の混乱と、立て続けに手続的に不合理な改正が行われてきている。

自治体の大混乱については、次の新聞報道は地方税の問題としているが、これは所得税改正の反映に過ぎないのである。

*京都新聞（2006年6月25日号）

えっ!? 住民税最大7・4倍 京の区役所 説明求め列

住民税の値上がりに説明を求めるお年寄りら。順番待ちの人も多い（京都市左京区役所）。国による高齢者の非課税措置などの廃止で、年金受給者の住民税が値上がりした。京都市の試算では、課税対象者が4万人近く増え、納入額は最大7・4倍になると想定されており、説明を求めるお年寄りが市の各区役所を連日訪れている。

今年4月の改正地方税法の施行で、個人住民税の老年者控除と非課税措置が廃止、公的年金等控除も縮小された。非課税だった年金収入約266万円以下の人も課税されることになった。市のモデルケース（配偶者と2人暮らし）では、年金収入が年間250万円の人の場合、これまでの非課税から1万3800円を課税される。同300万円の人は6600円から4万9300円に上がる。市は本年度、65歳以上からの新たな増収を15億3000万円と見込む。同法は2004、05年に相次いで改正され、市は今年2月の市民新聞の折り込みで内容を説明したが、納入通知書を受け取った高齢者が今月12日ごろから区役所に詰めかけ始めた。16日までの1週間で前年比2倍の約6400人が訪れた。区役所は窓口整理員を雇って対応しているが、1時間以上待つ人もいる。左京区役所を訪れた男性(68)は「今年は住民税と国保料を合わせ10万円以上も負担が増えた。増税のことは聞いておらず、納得できない」と話していた。

また、会社法改正に伴う役員報酬等の税制上の扱いについての十分な議論もなしに、突如実質一人会社に係るオーナー役員給与の損金算入制限が導入され、定時定額要件も緩和された。しかも、平成18年1月17日の閣議決定で損金算入できる業績連動型役員報酬制度も導入され、法律案はその後の2月3日に国会に提出され、3月27日に可決、4月

から施行となった。これにより、法人税法34条は従来の原則損金算入から、原則損金不算入へと180度変わり、35条に「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」も加えられた。ところが、これらの新規定の適用要件については不明確なものも少なくなく、すでに事業年度が始まっているのに、その具体的要件が明確ではなく、しかも専門家が右往左往させられていた。対象企業にこの改正内容が十分伝えられて、議論がなされたわけでもない。その後、実施に様々な障害があることも判明し、不算入基準額の改正をせざるを得なくなっている（法人税法施行令72条の2等参照）。

本件は、そうした不合理な立法が繰り返されている最中に生じたものであることをまずご理解いただきたい。

本件の争点とその意味

本件の具体的事案及び争点は、平成16年3月26日に成立し、同月31日に公布された法律により、所得税における「土地、建物等の譲渡損」の損益通算（他の所得と譲渡の損を通算すること）が否定され、譲渡損規制の適用が1月1日に遡及適用された点である。被告は、これを後述の期間税の法理を根拠に違憲ではないとしているが、通常の期間税の法理が適用される事案ではないことを、この意見書では具体的に示したい。

本意見書で問われている問題は、よりわかりやすくいうと、次のような事例と同じなのである。

Aさんは、親の介護資金捻出のため、2005年12月10日に、自己所有の物件の譲渡益が非課税であることを確認した上で、売却することを決意し、不動産業者に仲介を依頼したが、譲渡できたのは2006年1月30日であった。Aさんは、当該収入金額全額を親の介護資金として支出した。ところが、同年3月26日に国会で成立し、同月31日に公布され、翌4月1日から施行された改正所得税法では、当該物件の非課税措置は撤廃され、しかも、同年1月1日からの譲渡行為に課税措置が適用されることになった。そのため、2007年3月の確定申告義務が生じ、予期していなかった高額な所得税負担も強いられ、親の介護措置を中断せざるをえなくなったが、財務省の説明によると、所得税は期間税であるから、12月31日の暦年終了時までの改正がなされていれば新法の規定が当該年度の所得に適用されるので「期間税の法理」により憲法上問題ないという。

このような説明を裁判所が是認するかどうか。本件で問われているのは、まさにこの問題である。なお、本件は上記の非課税措置廃止とは異なるように受け止められるかもしれないが、ある所得の損失が他の課税所得と相殺でき、減額できることは、単なる非課税以上に、当該金額相当額がマイナスにできるという点でより軽減効果の強いものであり、そ

れが事後の法律によって課税されることの負担効果がより強いものであることに留意いただきたい。

遡及効と我が国の学説・判例

憲法第84条の定める租税法律主義は、納税者の法的安定を図り、予測可能性を与えることを目的の一つとしており、行為時に非課税だった取引が事後の法改正により遡及的に課税されるのでは、納税者は税負担のない取引を安心して選択することはできない。そのため新法（改正法）を公布日より前に遡及して施行し又は適用することはこの目的に反し、納税者の不利益に変更する租税法の遡及効は租税法律主義に違反すると解されている。このことは、学説や裁判例においてほぼ異論ないといってよい（例えば、金子宏『租税法（第12版）』（弘文堂、2007年、99頁）、北野弘久『税法学原論（第5版）』（青林書院、2003年、95頁）など。裁判例では、東京高判平成11年11月11日・税務訴訟資料245号261頁、等）。

この法理から、具体的法規を無効とした裁判例としては、福岡高裁那覇支部昭和48年10月31日判決（訟務月報19巻13号220頁）があり、これは過年度の誤って課税した租税の還付を不要にするために事後立法するという不合理な内容の高等弁務官布令17号改正3号の効力を否定したものであった。

その他の裁判例では、結論としては租税法律主義違反が退けられているが、それは不利益遡及が肯定されたわけではなく、争点が不利益遡及には見えても、実は遡及ではなく、過去の事実と構成要件が結合しているにすぎない事案であったからである。

この点を上記東京高裁平成11年判決は次の原審判決を引用して次のように説明している。なお、この高裁判決は、相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物についての相続税の課税価格を、路線価等ではなく取得価額とする旨の特例（以下「本件特例」という。）の効力発生前に被相続人が一定の財産を取得し、本件特例の効力発生後に相続が発生した事案に関するものである。

しかしながら、租税法規不遡及、遡及課税立法禁止の原則は、過去の事実や取引を課税要件とする新たな租税を創設し、あるいは過去の事実や取引から生ずる納税義務の内容を納税者の不利益に変更するいわゆる遡及立法を許さないとする趣旨のものである。そして、相続税において、納税義務を生じさせる過去の事実にあたるのは、被相続人の死亡等及びこれらに伴う財産の取得という事実であると解される（相続税法一条）。

したがって、本件特例の効力発生前に被相続人が死亡したことにより財産を取得した相続人に課される相続税について、本件特例を適用するという場合は、行政法規不遡及、遡及課税立法禁止の原則に反することになり許されないと解されるが、本件特例の効力発生前ないし本件中間答申の日の前に被相続人が一定の財産を取得したという事実は、相続税法における納税義務を生じさせる過去の事実には該当しないのであって、相続人に課される相続税の課税価格の算定に当たって、右財産に本件特例を適用することが直ちに行政法規不遡及、遡及課税立法禁止の原則に反するという事にはならないというべきである。

この判断は基本的に正しいといえよう。課税要件（被相続人の死亡）は、過去の行為（被相続人による一定の財産の取得）と何らかの関連を有している以上、過去の行為等との結合は避けられないからである。ただし、改正後に課税要件を充足した場合にしか課税できないのであって、改正前に課税要件を充足した場合には遡及することはできないのである。本件の場合、真の遡及効が問題となっている事案であり、新たな課税要件を改正前の事実遡及させている点で重大な憲法問題を引き起こしているのである。このことをよりわかりやすく説明したい。

不利益遡及と構成要件の遡及的結合の違い

遡及効禁止の問題を検討する際に、まず留意しなければならないのは、新しい租税法規の構成要件は必然的に過去の行為等と連動しているということである。例えば、2006年3月26日に国会で成立し、同月31日に公布され、翌4月1日から施行された新税法により、同年4月1日現在の不動産所有者に新たな保有税が課せられた場合、納税者は4月1日以前に不動産を購入した者であり、購入当時そのような不動産税はなかったが、2006年4月1日以後新たな負担が課されるようになる。このような場合、購入当時の税制をその後も維持しなければならないという憲法規範はないし、一定期日まで非課税であるという特別措置が存在していたような特殊事例でないかぎり、購入時の信頼を裏切った

わけでもない。なぜなら、購入時から新法制定までの間の不動産保有には新法規の下でも税負担がないからであるし、購入時の保有税非課税が将来の保有の非課税まで保証しているわけではないからである。

このように、租税の構成要件は過年度の行為等と必然的に係わらざるを得ないが、そのことが直ちに遡及禁止に抵触するわけではない。つまり、一見すると遡及適用と見える場合でも、構成要件の遡及的結合といえるにすぎない場合があり、これは違憲な遡及効とを区別しておかねばならない。

そこで、税法上の遡及効の問題を、具体的事例を示しながら、憲法上許容されているものと、違憲といわざるを得ない遡及効を示していきたい。

【不動産取得税の場合】

(1) Aさんは2006年1月4日に、不動産取得税は非課税とされている物件を購入したところ、2006年3月26日に成立し、同月31日に公布され、翌4月1日から施行されることとなった改正不動産取得税法により非課税措置が廃止され、その適用が同年4月1日からの不動産取得に適用され、そのため、Bさんはもう一つ不動産購入を考えていたが、断念した。

(2) Bさんは2006年1月4日に、不動産取得税は非課税とされている物件を購入したところ、2006年3月26日に成立し、同月31日に公布され、翌4月1日から施行されることとなった改正不動産取得税法により非課税措置が廃止され、その適用が同年1月1日からの不動産取得に適用され、Aさんの不動産取得行為も課税されることとなった。

「不動産取得」という「行為」を課税対象にしている場合には、当該行為が行われた時の租税規範が適用されることはいうまでもない。行為時に納税者が租税負担も考慮して、私法上の行為を選択するのであるから、それが事後の租税法規によって変更されては、租税法律主義の要請する予測可能性は根底から覆されることになるからである。しかし、改正後の行為については新たな租税法規が適用されるのも当然であり、その意味で(1)は全く遡及的要素がない事例である。これに対して、(2)は典型的な遡及効であり、購入時課税標準に含まれていなかった行為が、事後の立法により遡及的に課税要件に組み込まれ、課税標準が事後的に拡大したケースである。同時に、非課税であったわけであるから、行為時に租税債務は抽象的にゼロとして成立したにもかかわらず、事後法によって成立した租税債務の変動がもたらされたことになる。このように、憲法が遡及禁止で要請している

内容は、一旦成立した租税債務及び行為時の課税標準の事後立法による遡及的変更である。

行為時を基準とするのは、その時点で債務が成立するからだけではなく、納税者が行為時に納税義務の有無を考慮して自己の処分権限を行使するからである。自らの処分行為に伴う税負担とその限界をあらかじめ法律で定めて、予測可能性を保証するところに最大のポイントがある。

【相続税の場合】

(3) Cさんは2006年5月4日に父親がなくなり、2002年10月10日の契約に基づき当時は相続税が非課税とされていた保険金を受け取った。ところが、2006年3月26日に成立し、同月31日に公布され、翌4月1日から施行されることとなった改正相続税法により非課税措置が廃止され、その適用が同年4月1日からの相続に適用され、そのため、Cさんは多額の相続税負担を余儀なくされた。

(4) Dさんは2006年1月4日に父親がなくなり、2002年10月10日の契約に基づき当時は相続税が非課税とされていた保険金を受け取った。ところが、2006年3月26日に成立し、同月31日に公布され、翌4月1日から施行されることとなった改正相続税法により非課税措置が廃止され、その適用が同年1月1日からの相続に適用され、そのため、Dさんは多額の相続税負担を余儀なくされた。

(3)の事例は相続開始が2006年5月4日であり、その前に成立・施行されている相続税法が適用されるが、保険契約を締結した当時は相続税非課税であったという事例である。このような事例は、構成要件の遡及的結合といえる事例であり、課税対象となるものが過去の契約に基因しているとはいえ、相続時にはすでに新法が成立・施行され、相続開始時の租税法規によって課税標準が確定し、課税されている事例に過ぎない。このようなものまで、租税法律主義が納税者の予測可能性担保のために禁止しているというわけにはいかないであろう。新しい課税要件といえども過去の行為とは無関係ではあり得ないからである。

これに対して、(4)は相続開始時の相続税法では非課税であったものが事後的に課税標準に組み込まれ、租税負担の増加をもたらしたケースである。2002年の契約締結が問題なのではなく、2006年1月4日の相続開始があり、その時点の租税法規に基づく課税標準及び租税債務が事後法で遡及的に変更されたことになる。このような遡及的税負担は憲法が禁止している遡及効になることは異論がないと思われる。

いわゆる「期間税の法理」

これらに対して、期間税、つまり一定の期間の所得等を課税標準にしている税制については、やや異なる議論が展開されてきた。

(5) 2005年12月10日に成立し、同年末までに公布され、翌年1月1日から施行される所得税法では、従来非課税であった一定の譲渡行為も課税されることになり、税率も引き上げられた。そのため、Eさんは2006年に予定していた譲渡行為を断念した。

(6) Fさんは2006年3月までの勤労による収入が300万円で、源泉所得税も徴収されてきたが、2006年3月26日に成立し、同月31日に公布され、翌4月1日から施行されることとなった改正所得税法により税率が引き上げられたため、2006年度の年末調整では3月までの徴収額が少なかったことにより手取額が例年より少なかった。

これらは期間税といわれている所得税についての事例である。所得税は暦年を課税期間とするものであるから、暦年開始までに適用される租税法規が確定しているのが望ましいことはいうまでもなく、本来であれば期間開始前に改正措置をとっておかねばならない。

ところが、所得税法のような期間税については期間終了時点、つまり租税債務の成立時点までに改正法が成立していれば、違憲ではないかのような説明がなされているようであるが、その当否については慎重な検討を要する問題である。

確かに、期間税の場合は、(5)のように期間開始前の改正が望ましいとはいえ、一定の行為時点で租税債務が成立する租税と全く同じとはいえない側面もある。期間中の継続的な収入が課税対象となっている点や源泉徴収制度の存在なども考慮すると、租税債務の成立時点で新法が成立・施行されていれば、遡及効が生じていると解する必要はないかのようにもみえる。

しかし、(6)のケースでも厳密には、3月までは旧法が適用されており、旧法の下での所得稼得行為に対して遡及的に新法が適用されている側面は否定できない。それが、何故憲法的にもある程度許容されるかという点、期間税は期間中の所得を集計するという所得計算の手法を採り入れているからにすぎないのであり、納税者の予測可能性を否定することまで許容しているものではないことに留意すべきである。つまり、所得税法の課税標準は所得であり、3月までの所得について所得税の納税義務が生じることは予測されており、

その後の所得の増大、あるいは経費の増大如何によって、税負担の具体額も変わることが前提となっている。したがって、納税者としては当該行為を行った場合、仮にその当時の租税法規が改正されなかったとしても、租税債務が抽象的に発生しうることが予測できるものの、具体的租税債務額は未定であることには変わりがないからである。

このような期間税の性格を考慮した場合、適用税率については暦年終了時点の租税法規に基づいて課税するのは、期間中の所得を集計して計算することの反映に過ぎず、納税者の予測可能性や取引により獲得している過去の経済的成果を否定することまでを合理化するものではないといえよう。

期間税という性格から来る遡及効の緩和は以上のような意味にとどまるのであって、それ以上ではない。期間税という理由だけで、期間終了時までいつでも遡及改正が許されるとしたら、ある年の11月まで非課税としていた所得を年末の改正で課税所得に変更することも許されることになる。このような改正を憲法が許容すると強弁するのはあまりにも不合理であることは明らかであろう。かかる観点から、次の(7)を検討してみよう。

(7) Gさんは、所得税法では譲渡損が生じ場合、他の所得と損益通算できる制度になっているので、思い切って損失覚悟で2005年12月1日に所有する不動産を譲渡市場に出したが、なかなか買い手が見つかず、12月15日によく買い手が見つかり、翌年2月に譲渡契約を完了した。ところが、翌年3月26日に成立し、同月31日に公布され、翌4月1日から施行された改正所得税法により1月1日に遡って譲渡損の損益通算が認められないことになり、損失で相殺できる所得額については税負担がかからないとされていた行為時の租税規範が覆ってしまった。

これは二つの意味で期間税の法理で合理化できない。第1に、事後法で行為時の課税標準が変動されている。行為時に「損益通算」が認められているということは、当該損失で相殺される所得額は非課税とされており、課税標準がその分だけ圧縮されているのである。それを事後の法律で拡大するのは、期間税の法理でも許容できるものではなく、真の不利益遡及である。

第2に、本件の不動産の譲渡行為というのは期間中に継続的に生じるものとは異なり、一般の納税者にとっては一生に数回しかない例外的「行為」である。つまり、本件で問題となっている所得税の負担は単なる期間税という要素だけでは説明できず、行為税の要素も含まれているので、行為時に納税者が適正に税負担を判断できるものでなければならない。

被告は、このような遡及立法でも、立法目的が正当で、目的との関係で不合理でないかぎり合憲というが、何故このようにいえるのか、全く不可解である。立法目的が正当であ

れば、確かに、当該改正は合憲である。しかし、納税者が行為時に前提とした租税負担を覆す効果を持つような遡及適用を正当化するだけの立法目的は見出すことはできず、かかる遡及立法はやはり憲法的に許されないのである。期間税は期間終了時に債務が成立するとはいえ、終了時に集積される所得は期間中の個々の行為の積み重ねであることに留意しなければならない。個々の行為の選択に際しての納税者の予測可能性は憲法が保証しており、これと抵触しない範囲での構成要件の遡及的結合のみが許されるのである。所有権保障と租税法律主義を明記している現行憲法の下で、納税者の予測可能性を覆えし、事後的に課税標準を変質させる立法が正当目的を持つというのは、少なくとも現行憲法が許容するものではない。

なお、ドイツでは、不真性遡及効（＝要件事実への遡及的結合）と真性遡及（＝法効果の遡及効）とを区別しており、後者を違憲としている。期間税でも、真性遡及であれば違憲になる場合があり、具体的には次のような事例も引用されている。

1972年の9月に公布された改正法により、ドイツ国外に住所を移動していたドイツ人については、その年の1月1日からの所得について、従来ドイツの課税対象にしていなかった所得も課税対象に含めるように改正した。憲法裁判所は、伝統的な租税債務の成立時点を基準とする考え方を採用しながらも、制限納税義務者の場合は、改正以前の所得について源泉徴収により納税義務が完了しているものがあり、この既に完了した租税債務が事後の立法により変更されることになるので、違憲であるとした（1986年5月14日決定。詳細は、首藤重幸「法律規定における遡及効の類型と憲法原則」（ドイツ憲法判例研究会『ドイツの憲法判例（第2版）』信山社、2003年、377頁以下参照）。源泉分離の対象となって一旦成立した租税債務が事後的に変更されたことに根拠を求めているが、実質的には課税標準が事後的に変動させられたことにあるといってよい。また、ビルク教授は、船舶の特別償却制度を導入し、船舶の取得を誘導していた所得税法が年末の改正で、その年の1月1日に遡って特別償却を廃止する例などを違憲の例にあげている（Vgl. Dieter Birk, *Steuerrecht* 8Aufl., S.49）。

また、ティプケ教授はドイツの憲法裁判所が、期間税について遡及効禁止を十分に配慮していないとして、次のような批判をされている。

法治国家及び基本法に保証されている信頼保護の対象となるのは、信頼に基づく活動であり、税法の場合は、課税にとって重要な行為である。連邦財政裁判所及び連邦憲法裁判所の判例もこのことを認めている。連邦憲法裁判所1997年12月3日決定は信頼保護を自由権的に法的に重要な行為の時点に関連づけている（訳者注：この事案は、1996年12月7日に可決された法律により、1996年4月24日より後に締結された造船契約に基づいて製造された商船について、それまでの法律によって認められていた特別償却が認められなくなったことが問題となった。この特別償却は、その商船に関して購

入または製造の事業年度とそれに続く4事業年度に40%までの償却を認めるというものであり、改正案は当初1996年4月30日より後に締結された契約から特別償却を認めないということで、一般には知らされていた。しかし、議会での審議過程でこの期日が4月25日以降ということに変更された。多数意見はこれを合憲としたが、違憲とする少数意見もあったものである)。したがって、租税計画の安全性をもたらす制度としての遡及効禁止は、(納税者の)処分権(Disposition)保護の目的のために展開されねばならない。

(期間税の場合に基準とされている)法律効果の成立と租税要件の実現だけに向けられてきた遡及効という用語はこの目的を損なっている。法律効果は、例えば特別償却の効果のように、信頼に基づく行動からかなり後に生じことがあるし、他方で、市民が改正を考慮せざるを得ない場合は、法律の施行前に信頼保護がすでに失われることもありうる。・・・

正しくは、信頼の保護の上で重要な処分権を遡及効概念の基礎に据えねばならない。したがって、遡及概念のためには原則として次の二つの時点が決定的に重要となる。一つは処分権が経済的、法拘束的に行使される時であり、他の一つは、立法措置によって信頼保護が失われる時点である。このことから、法律効果と結びつけられた遡及概念は次のように修正されることになる。

もしある法律が、法律の成立(もしくは法の公布)前に決定したと評価しなければならない信頼に基づく行動に対してその法律効果を変更する場合には、一般的な遡及禁止という意味での遡及効が存在することになる、と。

【K.Tipke/J.Lang, Steuerrecht, 18Aufl. S.111f.,】

これらの学説は、私見と同様に、期間税というだけで、租税債務の成立以前であれば改正法を期間当初に遡らせて良いとするのではなく、期間税であっても行為時の信頼を覆すことを違憲とする主張であり、その理論的基礎は期間税であっても課税標準自体を遡及的に変更する措置は憲法上許されないという私見と同趣旨であるといえる。

なお、被告は土地市場への不測の影響を及ぼすおそれをあげて本件のような異常な遡及立法を合理化しようとしているが、それは改正作業を急ぐことの合理的理由にはなっても、遡及適用することの合理的根拠とはならない。このような理由で、遡及効が許されるならば、国会での審議が長引くので、贈与税の駆け込み節税対策を規制するために、改正前の贈与行為にも遡及適用するような改正法も許されることになる。

おわりに

以上のように、私は本件の改正措置は違憲であったと裁判所が明確に示すべきものであると考えている（学説では、他に高野教授も違憲と主張されている。「不動産譲渡損益通算廃止の立法過程にみる税制の不利益不遡及の原則」税務弘報2004年6月号154頁以下。）。これまでの租税立法でも、憲法的に見ておかしいと思われるものがあつたが、期間税の法理の安易な利用と訴訟の困難さが重なって、本件のような真の遡及効事案が争われることが少なかった。とりわけ、近年の租税法改正においては、前述のような不意打ち課税が多く、しかも、大事な改正項目が納税者に目立たないように行われるケースが目立っていた。不意打ち課税に加えて、本件のような遡及的課税まで裁判所が許すべきではない。裁判所が毅然と憲法に基づく租税立法を要求することが、日本の税制立法をより民主主義社会にふさわしいものに変えていくことにつながると信じている。